

1505720-68.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505720-68.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505720-68.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2066228/2020 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 10460856 - 54º D.P. CID. TIRADENTES,

1263/20/354 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 2066228 - 54º D.P. CID. TIRADENTES,

1263/20/354 - 54º D.P. CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS é acusado de, agindo em concurso como o adolescente Danilo Alves da Costa, de 17 anos de idade, trazer consigo, para venda a terceiros, sem autorização legal ou regulamentar:

60,1g (sessenta gramas e um decigrama) de Cannabis sativa L, conhecida como "maconha", erva que contém a substância Tetrahydrocannabinol, dividida em 43 invólucros plásticos;

3,9g (três gramas e nove decigramas) de cocaína em forma de crack, distribuída em 8 unidades conhecidas como "pedras";

6,4g (seis gramas e quatro decigramas) de cocaína, distribuída em 32 invólucros

plásticos conhecidos como Eppendorfs.

O denunciado e o adolescente estavam diante de uma quadra de futebol, em conhecido ponto de venda de drogas, quando Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, se aproximaram do local. Os agentes correram, o que motivou a abordagem pelos Policiais. Em poder deles, na mochila que o denunciado portava, os Policiais encontraram as drogas. Na mochila também havia R\$ 97,00 em dinheiro, produto da venda de drogas, além de anotações próprias do tráfico de entorpecentes.

As drogas, o dinheiro e os demais objetos foram apreendidos (fls. 11/12). Laudo de constatação afirmou tratar-se de substâncias que se causam dependência (fls. 15/18).

Após notificado o réu (fls. 149) foi apresentada a sua resposta à acusação (fls. 153). Inviável a absolvição sumária, a denúncia foi recebida (fls. 154/155), designando-se a audiência de instrução e julgamento.

Encontram-se ainda nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), o boletim de ocorrência (fls. 6/10), o auto de apreensão (fls. 11/12), os laudos preliminar (fls. 15/18) e definitivo (fls. 213/215)

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa, em razão da confissão do acusado, deixou de requerer a absolvição. Contudo, quanto a fixação das penas requereu: a) pena base: que seja estabelecida no piso legal ante as favoráveis circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do CP) b) agravantes e atenuantes: o acusado contava com 18 anos e confessou os fatos; c) causas de aumento e diminuição de pena: presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a redução na fração de 2/3; considerando a majorante do art. 40, IV, da mesma lei, requereu que o aumento não seja superior a 1/6 e o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da mesma lei uma vez que não restou devidamente provado nos autos; d) regime inicial de cumprimento de pena: considerando o montante de pena aplicado, a primariedade, as favoráveis circunstâncias judiciais e o tempo de prisão provisória, que seja estabelecido o aberto; e) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos: presentes os requisitos do art. 44 do CP, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos; f) recurso em liberdade.

É o relatório. Decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e do laudo de constatação provisória (fls. 15/18), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 213/215), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva, vejamos.

O policial Leonardo declarou que não se recorda do acusado. Lida parte da denúncia recordou-se dos fatos. Estavam de patrulhamento de Rocan. Entraram numa praça. Ao visualizarem a equipe policial duas pessoas fugiram e tal fato trouxe suspeitas. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Os fatos ocorreram pela manhã. Um deles era menor de idade. Eles confessaram a prática delitiva mas não quiseram dizer para quem trabalhavam. Dentro de uma sacola que estava com o acusado havia entorpecente, dinheiro e anotações de tráfico. Havia maconha, cocaína e crack. Pela quantidade apreendida, o entorpecente seria destinado a terceiros, tudo embalado. Ele foi preso na posse da sacola.

Edson, policial militar, reconheceu o acusado de uma ocorrência de tráfico na Rua Semente do Amor. Recordou-se que visualizou dois jovens andando pela via.

Suspeitaram e eles tentaram se evadir. Um deles estava com uma quantidade de entorpecente, maconha, cocaína. Eles estavam com dinheiro. Um deles era menor. Não se recorda se o entorpecente estava com o menor ou com o acusado. Foi o parceiro que fez a busca pessoal então ele saberia dizer com exatidão. Pelo que se recorda

eles não admitiram a prática delitiva. Eles estavam com maconha e cocaína. Dinheiro, era pouco, cerca de 20,00. O local é próximo a um campo de futebol. Pois bem.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Além da materialidade, do flagrante e de toda a prova oral colhida, idônea a fundamentar o decreto condenatório, temos a confissão do acusado obtida em juízo, vejamos.

Jonathan declarou que tem 20 anos de idade. Mora com a mãe, irmã e com o pai. Já trabalhou em uma lanchonete e de ajudante de pedreiro. Trabalhou no Point do Aurea, Saturnino Pereira, por dois anos. Tinha 16 anos. Respondeu por dois traficos quando ainda era menor. Ficou internado em Juquitiba por seis meses ficou internado por uso de droga, Ficou na clinica Caeirós. Não conseguiu parar de usar drogas. Está condenado em um roubo por 7 anos e 9 meses. Nesse roubo, um dos comparsas faleceu em confronto com a polícia. Admite que estava no trafico de drogas. O outro era usuário, estava ali para comprar. O entorpecente foi encontrado no muro de um prédio. Não estava com uma sacola. Foi preso pelos policiais que foram ouvidos no dia de hoje. Não está recebendo visitas na cadeia. Não conhece o adolescente e não sabe a razão pela qual ele prestou as declarações de fls. 22. Não estava com o entorpecente que consta nas anotações. Estava com muito menos.

Pois bem.

Como se percebe, não restam dúvidas quanto a autoria delitiva, inclusive da causa de aumento prevista pelo artigo 40, VI da Lei de Drogas porque como se percebe a fls. 06/10, houve a apreensão de um adolescente o qual se encontrava na companhia do acusado, no caso D.A.C. que também foi apreendido pela prática de ato infracional, e que ouvido a fl. 22, deixou claro que estava ali em companhia do réu para "aprender a mercancia de entorpecentes", fl. 22.

Contudo, quanto a causa prevista pelo inciso III do artigo 40, entendo ser o caso de exclusão porque um campo de futebol não caracteriza, nos termos lei, uma sede de entidade recreativa. Para tanto, é preciso que haja uma estrutura mais organizada e apta a suportar encontros e disputas desportivas, o que não restou comprovado nos autos.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em

posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, afasto a agravante referente a calamidade publica eis que, a meu sentir, não houve prova alguma de que o circunstancia tenha agravado o crime ou facilitado sua pratica. Não há prova de nexos causal. De igual forma, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena a quem do mínimo lega.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu era primário por ocasião dos fatos e não possuía maus antecedentes, fls.48/49, 95 e 185/186. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. Também não é possível a conclusão inversa com base em fato típico praticado posteriormente ao fato em julgamento. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Na medida em que presente a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, VI, aumento a pena em, 1/6, a qual resta definitivamente fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa. Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS, RG nº 5.222.007-1-SP, demais qualificações nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º cc artigo 40, VI,

ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Ademais, ao que consta, está preso por outro processo.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls.11/12). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória. Isento de custas.

São Paulo, 14/04/2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA